

1500083-10.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... médios---, além de petrechos próprios para o tráfico (balança de precisão e um rolo de sacos plásticos). A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida já seriam suficientes para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Como já visto, com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 1.880,00 em dinheiro sem comprovação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500083-10.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-10.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20:57 horas, nesta cidade de Araçatuba, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, um mil cento e vinte e cinco gramas e sessenta e sete decigramas (1.125,67 g) de Benzoilmetilecgonina, divididos em doze (12) microtubos e cinco (5) tijolos médios de cocaína, substância entorpecente determinante de dependência física e psíquica.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar a fls. 240/242. A denúncia foi recebida a fls. 249/251. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas

arroladas pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 294/299).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 295/298), ao passo que a Defesa, por sua vez, requereu absolvição do acusado em razão do reconhecimento da ilicitude probatória. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a liberação da motocicleta e dos valores apreendidos (fls. 303/309).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade do processo por vício na colheita de provas, em decorrência de suposto ingresso irregular dos policiais no domicílio onde ocorreu a apreensão da maior parte da droga, bem como dos petrechos e do dinheiro.

Com efeito, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” (negritei).

Ocorre que a atuação policial não foi maculada pela nulidade alegada, pois conforme demonstrado no decorrer da instrução e como adiante se explicitará, o réu, após a abordagem inicial que resultou na apreensão de doze pinos com cocaína, informou aos policiais que estava traficando, que tinha mais droga na residência e autorizou o ingresso dos mesmos no imóvel, os acompanhando até o local onde ela foi apreendida, não havendo que se falar, portanto, em invasão de domicílio. Analisando situação semelhante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO OBJETO: FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO VERIFICADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Sobre a suposta invasão de domicílio (galpão ocupado pacificamente), apesar da irresignação defensiva, houve prévio consentimento ao ingresso policial, conforme os depoimentos colhidos em juízo. III - Assente, pois, que, “Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade” (AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). IV - As instâncias ordinárias, mediante exaustivo exame fático probatório, concluíram que a falsificação do documento apresentado pelo paciente aos policiais (Carteira de Trabalho - CTPS) não era grosseira, sobretudo, porque não foi possível tal constatação de plano. V - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreitado writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 688.309/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em

9/11/2021, DJe de 17/11/2021). - negritei

Assim, afasto a preliminar arguida, eis que legítima a atuação policial e, por consequência, lícita a prova colhida nos autos.

No mérito, é procedente a ação penal.

A materialidade do crime veio comprovada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 21/23, laudos de constatação prévia de fls. 26/27 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 111/116, que resultaram positivos para cocaína.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Com efeito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime. Disse que no dia dos fatos estava indo devolver a motocicleta pertence ao seu pai. Emprestou a moto porque naquela semana choveu bastante e possui apenas uma bicicleta para ir trabalhar como auxiliar de higiene e limpeza em uma UBS. Trabalha registrado há dois anos. Esqueceu os doze “cartuchos” de cocaína em seu bolso. Seu genitor reside na Rua Aviação e estava no meio do caminho quando um rapaz lhe telefonou dizendo que queria pagar a quantia de R\$ 40,00 devida em razão de droga que forneceu a ele no dia anterior. Parou para conversar com o rapaz e não viu a viatura se aproximar porque estava de costas. Saiu do local, onde existe uma pracinha, virou e os policiais deram ordem de parada. Parou e foi abordado. Os policiais realmente encontraram a droga em seu bolso. O outro policial que participou da abordagem, mas que não foi ouvido em Juízo, lhe perguntou sobre o proprietário da motocicleta e quem seria Donato. Respondeu ao policial que Donato é seu pai. Confessou aos policiais que estava no local para receber dinheiro pela venda de droga. Falou para os milicianos onde morava, mas eles não acreditaram. Toma losartana e hidroclorotiazida, remédios controlados. O policial “puxou” o seu RG para verificar sua residência e constatou o endereço de uma fazenda onde morou e trabalhou em Santo Antônio do Aracanguá. Explicou ao policial que morou na fazenda anteriormente e se mudou para a cidade, mas ele não acreditou. O policial revirou sua carteira, encontrou a receita médica e disse que iriam até sua casa. Ficou em silêncio e foi colocado no interior da viatura. O outro policial conduziu a motocicleta até o quartel, onde a deixaram. Em seguida, foram até sua residência. Os policiais entraram e encontraram o entorpecente. Não falou para os policiais que tinha mais droga na casa. Não autorizou o ingresso na residência. Permaneceu algemado no interior da viatura e não viu o que aconteceu. A droga apreendida realmente estava na casa e era sua. Tinha cerca de um quilo, cento e setenta gramas de cocaína. Ganhou R\$ 5.000,00 em dinheiro no Atabir em dezembro e deu R\$ 1.800,00 para sua esposa efetuar o pagamento do aluguel, água, luz e comprar o leite do filho. O guarda-roupa possui seis portas “de abrir”. As portas do meio e da direita são utilizadas por sua esposa. O dinheiro estava guardado em um potinho perto de perfumes na porta do meio. A droga estava na parte de cima do seu lado do guarda-roupa. Começou a vender droga cerca de um ou dois meses antes. Trabalhava em dois empregos. Conseguiu comprar a enorme quantidade de droga apreendida porque achava que tinha amigos, mas agora se afundou e está endividado. Perdeu o emprego do período noturno em razão da pandemia e passou a trabalhar somente durante o dia na UBS. Recebe a quantia mensal de R\$ 1.360,00, além de ticket no valor de R\$ 160,00. Tinha balança de precisão em sua casa. Utilizava o rolo de plástico apreendido para embalar alimentos e os congelar no freezer. No começo, não embalava cocaína para revenda. Tinha acabado de receber o entorpecente apreendido. Já foi processado por tráfico e cumpriu a pena. A motocicleta pertence a seu pai e ele a emprestou somente naquela semana para ir trabalhar. Não conhecia os policiais. Cumpriu a pena relativa ao crime anterior de 2015 a 2016. Tem quatro filhos e queria uma oportunidade.

E a confissão parcial do acusado foi corroborada pela prova oral produzida em juízo.

Com efeito, o policial Marcos Roberto Sales, ouvido em Juízo, disse que estava com o cabo Gleison em patrulhamento pela Avenida João Arruda Brasil, sentido zoológico, quando avistaram dois indivíduos em frente ao Senac, um de moto e outro de bicicleta, que estava entregando algo para o motociclista. Os indivíduos se evadiram em sentidos opostos ao avistarem a viatura. Decidiram abordar o motociclista, o acusado Luiz. Em revista pessoal, localizaram um frasco na bermuda do acusado contendo doze pinos com cocaína. O réu lhes confessou que fazia a venda de drogas no sistema "delivery", no qual os usuários ligavam ou entravam em contato via whatsapp e ele ia entregar o entorpecente, bem como que tinha mais droga na casa dele. Dirigiram-se até a residência e, com autorização do acusado, revistaram o imóvel e encontraram dinheiro e mais de um quilo e cem gramas de cocaína no guarda-roupa dele. A cocaína estava fracionada em várias porções. Localizaram também um caderno de anotações, balança de precisão e um rolo de plástico para embalar droga, também no interior do guarda-roupa no quarto do réu. O dinheiro estava no guarda-roupa próximo da droga. Apreenderam mais de R\$ 1.800,00 em dinheiro. No momento da abordagem, o acusado tinha a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro. Não conhecia o réu, que autorizou o ingresso dos policiais na residência e lhes relatou que a convivente dele não sabia de nada. O acusado lhes falou que estava vendendo droga há algum tempo para sustentar a família porque tinha perdido o emprego. O entorpecente estava na parte de cima do guarda-roupa, que possui três portas, e o dinheiro em notas diversas estava ao lado da droga. O réu confessou que o dinheiro era produto do tráfico. A droga estava acondicionada em um saquinho tipo de bexiga e o dinheiro estava ao lado. O acusado não lhes falou nada sobre ter recebido o dinheiro em bingo Atabir. A abordagem foi motivada pela conduta dos dois indivíduos, que estavam em frente ao Senac e, ao perceberem a presença da viatura, o homem com a bicicleta saiu em sentido à Rua Saldanha Marinho, enquanto que o réu sairia em sentido ao zoológico. Não abordou o acusado anteriormente. Não conversou com o réu sobre a motocicleta.

E não há porque se colocar em dúvida a versão do policial, porque como qualquer outra testemunha ele presta compromisso de dizer a verdade, e não viria a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizou. Note-se que não há prova nos autos de qualquer desavença anterior entre o policial e o réu ---sequer se conheciam---, de forma que seu depoimento merece credibilidade, pois não teria qualquer motivo para acusar injustamente um inocente. Enfim, não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má-fé.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT 416/96).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2756).

No mais, ouvido apenas na fase administrativa, o policial Gleison corroborou integralmente a versão judicial de Marcos, inclusive no tocante à autorização do réu para o ingresso dos milicianos na residência onde ele informou possuir mais entorpecente em depósito.

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida realmente pertencia ao acusado e que houve expressa autorização de sua parte para o ingresso dos policiais na residência onde a maior parte do entorpecente foi localizada.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que trazia consigo e tinha em depósito uma elevada quantidade de droga, ou seja, 1.125,67 gramas de cocaína ---acondicionados em doze microtubos prontos para imediata comercialização e mais cinco tijolos médios---, além de petrechos próprios para o tráfico (balança de precisão e um rolo de sacos plásticos). A quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida já seriam suficientes para demonstrar a finalidade do tráfico de entorpecentes. Mas não é só. Como já visto, com o réu foi apreendida a quantia de R\$ 1.880,00 em dinheiro sem comprovação de origem lícita, ou seja, o produto do crime. Neste ponto, ressalto que o "recibo de pagamento de prêmios - Atabir da sorte" (fls. 146/147) não comprova a origem do numerário apreendido no interior do guarda-roupa ao lado da maior parte da droga e dos petrechos encontrados, sobretudo porque decorrido mais de um mês entre a data do suposto recebimento ---sorteio em 05/12/2021 (fls. 146/147)--- e a data dos fatos ---08/01/2022 (fls. 01) e, malgrado todas as despesas relacionadas com aluguel, água, luz e leite que o réu alegou que seriam pagas com a quantia, a esposa dele ainda estaria na posse da integralidade dos valores por ela recebidos para tanto. Em relação ao vídeo informal de declarações da esposa do acusado, cujo "link" foi indicado a fls. 124, destaco que a versão é parcialmente contraditória até mesmo ao que o réu disse em Juízo ---ela afirmou que o acusado lhe entregou os R\$ 5.000,00, ao passo que ele, como já visto, alegou que deu à esposa a quantia apreendida de R\$ 1.800,00--- e em nada altera a conclusão sobre a ausência de demonstração da alegada origem lícita do numerário em exame.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente, mesmo porque o réu admitiu em Juízo que estava traficando há um ou dois meses.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta antecedentes criminais (condenação por tráfico de drogas certificada a fls. 41/43). Atendendo, ainda, às demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, notadamente a elevada quantidade de droga apreendida (1.125,67 gramas de cocaína), fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base ao patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora tecnicamente primário, o acusado já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas, como já visto. Além disso, trazia consigo e tinha em depósito uma expressiva quantidade de cocaína (1.125,67 gramas), distribuída em doze microtubos e cinco tijolos de

tamanho médio, além de petrechos típicos para o embalo de drogas (balança de precisão e rolo de sacos plásticos). Tais circunstâncias permitem concluir que ele não se trata de mero traficante ocasional, mas sim que se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico meio de vida e fonte de renda, mesmo porque admitiu que estava há um ou dois meses traficando. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Apelo Ministerial pleiteando a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia – R. Sentença reformada – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes estatais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Necessidade de fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela voluptuosa quantidade de entorpecentes apreendida, pela diversidade das drogas, bem como pela existência de maus antecedentes do réu – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Circunstância agravante relativa ao cometimento do delito durante estado de calamidade pública configurada, diante de sua natureza objetiva – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que o acusado se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive, possui condenação criminal definitiva, também por tráfico de drogas, não obstante tal fato não gerar reincidência nos autos em comento – Causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/06 incidente, haja vista o resultado do laudo proferido nos autos de incidente de dependência toxicológica, o qual concluiu pela semi-imputabilidade do réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com o quantum da reprimenda imposta e, ainda, com os maus antecedentes do acusado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1504608-43.2020.8.26.0526; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022). “Tráfico – condenação não contrária à evidência dos autos – Maus antecedentes reconhecidos com base em certidões que revelam reincidência – todavia, afastada a agravante na segunda etapa, não configurado indevido “bis in idem” – recidiva excluída porque a condenação invocada não cita a data de trânsito em julgado para a defesa – Natureza da droga – parâmetro que deve ser ponderado em conjunto com o volume de entorpecente apreendido – propagação limitada do tóxico quando recolhida pequena quantidade – Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – inviabilidade – presença de má antecedência – adequada fixação do regime inicial fechado – Pedido revisional deferido para redução das penas.” (TJSP; Revisão Criminal 2193981-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022). “APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Prova de acusação consistente – Confissão judicial que, embora não seja dotada de caráter absoluto, se mostra verossímil e se coaduna aos demais elementos de prova - Relatos dos policiais militares firmes e coerentes – Desnecessário que o réu seja surpreendido em situação de mercancia para que se configure o estado de flagrância – Quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes a denotar que a droga apreendida destinava-se à venda - Fato, inclusive, reconhecido pelo réu em interrogatório – PENA - DOSIMETRIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - Art.33, § 4º, LEI 11.343/2006 - INAPLICABILIDADE - Redução que deve se voltar para as hipóteses em que há equiparação legal à condição de traficante, mas, na verdade, a pessoa acusada dessa espécie de delito não faz da narcotraficância meio de subsistência - Ausência dos requisitos autorizadores da aplicação do redutor – Circunstâncias da

prisão em flagrante que permitem concluir que o acusado se dedica à atividade criminosa - Diversidade de entorpecentes, quantidade e forma de acondicionamento da droga - Recorrente que, embora tecnicamente primário, ostenta antecedentes criminais, tendo, inclusive, sido anteriormente processado pelo mesmo delito - REGIME PRISIONAL - DIVERSO DO FECHADO - INADMISSIBILIDADE - Proibição legal - Artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 - Conduta extremamente grave, devendo receber todo o rigor penal • Sentença condenatória mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0242882-47.2010.8.26.0000; Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2011; Data de Registro: 17/11/2011 ---destaquei). Ausentes outras circunstâncias modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedicava ao tráfico de cocaína, substância altamente nociva, não se enquadrando o delito em questão na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, vez que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. A insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTCRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na que a manteve.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga

apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União os valores descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, pois se tratam de produto do crime.

Por outro lado, diante da comprovação da propriedade da motocicleta apreendida (fls. 28) e da inexistência de prova nos autos que infirme as declarações prestadas por Donato Benedito da Silva no sentido de que não tinha conhecimento sobre a utilização do veículo para a prática do tráfico (fls. 72), revogo a ordem de busca e apreensão da motocicleta apreendida (fls. 282) e defiro a sua restituição ao legítimo proprietário, anteriormente já nomeado depositário do bem (fls. 73). Providencie a serventia o necessário, comunicando-se a autoridade policial e cobrando-se a devolução do mandado, com urgência, independentemente de cumprimento.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA